Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
2ª Vara Cível da Comarca de Santa Cruz do Sul

Rua Ernesto Alves, 945 - Bairro: Centro - CEP: 96810144 - Fone: (51) 3711-2952 - Email: frsantcruz2vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5012719-54.2021.8.21.0026/RS

AUTOR: CARINE TOEBE

RÉU: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

É evidente que os homens querem dizer coisas distintas e separadas quando falam de Constituições e governos. Por que estes termos são usados distinta e separadamente? Uma Constituição não é um ato de governo mas de um povo constituindo um governo. Governo sem Constituição é poder sem direito.

Todo poder exercido sobre uma nação deve ter um começo. Ele deve ser delegado ou tomado. Não há nenhuma outra fonte. Todo poder delegado é confiança e todo poder tomado é usurpação. O tempo não altera a natureza nem a qualidade de nenhum deles.

Tomas Paine. In: Os direitos do homem. Tradução: Jaime A. Clasem. Petrópolis: Vozes, 1989, p. 160.

(...) percebe-se, desde logo, que o princípio da dignidade da pessoa humana não apenas impõe um dever de abstenção (respeito), mas também condutas positivas tendentes a efetivar e a proteger a dignidade dos indivíduos. ***Nesta linha de raciocínio, sustenta-se, com razão, que a concretização do programa normativo do princípio da dignidade da pessoa humana incumbe aos órgãos estatais, especialmente, contudo, ao legislador, encarregado de edificar uma ordem jurídica que atenda às exigências do princípio.***

*SARLET, Ingo Wolfgang**.** Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais: na Constituição Federal de 1988. 2º ed. rev. amp. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002, p. 112.*

Vistos.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória", ajuizada por **CARINE TOEBE** contra o **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL** mediante a qual pretende compelir o demandado ao fornecimento do fármaco *Cetuximabe (Erbitux)* 5mg/ml na dose de 900mg, a cada 14 dias, por período indeterminado, apresentando laudo do seu assistente médico no qual é atestado ser portadora de segundo a inicial, e de acordo com os atestados médicos, a demandante apresenta neoplasia maligna de cólon (CID 10: C18). Refere que em razão da sua delgada condição financeira e do alto custo do medicamento, solicitou administrativamente o fornecimento, não obtendo êxito. Aduziu que, não utilizando a medicação, sua saúde estará comprometida. Diante da impossibilidade de aguardar trâmites burocráticos em detrimento do seu direito à saúde, requereu, em sede liminar, a antecipação de tutela, o fornecimento da medicação. Pugnou pela AJG. Juntou documentos.

No E4 foi concedido o benefício da gratuidade judiciária e determinada a emissão de nota técnica pelo NATJus, que sobreveio no E9.

Intimadas as partes para se manifestarem sobre o resultado na nota técnica e acerca do TEMA 793 do STF, E11.

O Estado postulou a emenda da inicial para inclusão da União, E16, e a autora a concessão do medicamento, E17.

O Ministério Público aportou parecer pela inclusão da União e remessa do feito à Justiça Federal, E22.

Determinada a remessa ao NATJus para reavaliação, E24, trazida no, E26.

Concedida a tutela de urgência noE28.

No E36 o ERGS apresentou contestação, defende a inclusão da União, destacando o Tema 793 do STF, definindo a competência da União, bem como de a obrigação de fornecer tratamento médico após a necessidade de submissão à atendimento na rede pública, para ser encaminhada a um CACON, porquanto o tratamento está disponibilizado no âmbito da Saúde Pública, alegando responsabilidade da União. Pontuou a ausência de laudo médico pelo SUS. Ao final, discorreu sobre o alto custo do medicamento e requereu a improcedência da ação.

Houve réplica, E39.

No E41 foi repelida a prefacial e indeferida a inclusão da União.

Instados a se manifestarem sobre a dilação probatória, ambas as partes pediram o pronto julgamento (E46 e 50).

Vieram os autos conclusos.

Relatei. Passo a fundamentar.

O Juízo é competente em razão da nacionalidade, matéria e hierarquia. As partes gozam de personalidade e capacidade judiciária e são legítimas. Não há nulidades arguidas e, tampouco, identificadas e, sequer, exceções ou questões prévias que obstem ao conhecimento do mérito da causa.

Ao examinar a prefacial, assim me pronunciei:

Primeiramente, convém salientar que este magistrado tem entendido pela <u>não inclusão da União no polo passivo</u> e, consequente, declínio de competência à Justiça Federal, mesmo considerada a decisão proferida pelo STF no RE 855.178, estabelecendo a seguinte tese, ao julgar o Tema 793:

> *Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.*

Tenho adotado o entendimento de que tal tese reafirma a responsabilidade solidária dos entes públicos, cabendo à parte autora, quando do ajuizamento, optar quanto ao ente contra o qual postulará judicialmente a medicação da qual necessita, por prescrição médica, sob sério risco à sua saúde, sem condições de custeamento, em face de sua parca situação econômica.

Nessa linha do posicionamento adotado, o Supremo Tribunal Federal teria reafirmado o entendimento já consolidado, no âmbito daquela Corte Superior, a respeito da responsabilidade solidária dos entes federados pelo fornecimento de serviços de saúde, <u>assegurando a possibilidade de ressarcimento entre os entes públicos</u>. Assim, como já vinha entendendo anteriormente, considerada a solidariedade, a demanda pode ser ajuizada contra qualquer dos entes federados.

Recentemente fixou o STF, em embargos declaratórios:

> *CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.* ***É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente****. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020). Grifei.*

Colaciono como exemplo, ementa de recente decisão do TJRS:

> *AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. ADULTO INCAPAZ - SÍNDROME DE DOWN. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RE 855.178/SE – TEMA 793 – DO E. STF. REJEIÇÃO. MÉRITO. HIPERTENSÃO PULMONAR TRAMBÓLICA CRÔNICA E EMBOLIA PULMONAR COM MENÇÃO DE COR PULMONALE AGUDO - CID 10.126.0 E 10.127.2. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - RIOCIGUAT. PROBABILIDADE DO DIREITO DO RECORRIDO EVIDENCIADA. RISCO DE MORTE DECORRENTE DA EVOLUÇÃO DA MOLÉSTIA. PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – ART. 300 DO CPC DE 2015. Preliminar.* ***Evidenciada a legitimidade passiva do Estado do Rio Grande do Sul, e o descabimento do litisconsórcio passivo necessário com a União, em razão da solidariedade dos Entes Públicos na prestação da saúde - art. 196 da Constituição da República -, consoante estabelecido no julgamento do RE n° 855.178/SE – Tema 793 -, do e. STF, independentemente das atribuições de cada ente público, objeto de compensações na via administrativa, consoante o art. 35, VII, da Lei Federal nº 8.080/90. Precedentes deste tribuna****l. Mérito. I -[...]. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento desprovido (Agravo de Instrumento, Nº 70082894494, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 07-05-2020). Grifei.*

Embora reconheça a existência de posicionamento contrário, entendo que segui-la, neste momento, determinando a inclusão da União no polo passivo - com imperioso declínio de competência -, traria maior morosidade na solução da lide, o que é decisivo, e muitas vezes irreversível, em especial quando há gravidade da doença da parte autora (no caso concreto, câncer).

Destarte, afasto a preliminar arguida pelo réu e indefiro a inclusão da União no polo passivo.

No mérito, assinalo que incumbe ao Estado proporcionar meios visando a alcançar a saúde dos cidadãos, nos termos do artigo 23, inciso II, da Constituição Federal.

O direito à saúde é consectário do direito à vida, configurando-se como direito individual fundamental, de aplicação plena e imediata.

Ademais, o fornecimento gratuito de medicamentos aos hipossuficientes, como no caso em apreço, insere-se na obrigação do Poder Público em cuidar da saúde e da assistência pública, por força do estatuído nos artigos 196, 198 e 200 da Carta Magna.

No que toca à carência de dotação orçamentária para o atendimento da despesa necessária para atender tais situações, não é motivo para excluir a responsabilidade do Estado.

A proteção à vida e à saúde deve ser prioridade absoluta do Poder Público, como alhures anotado, incumbindo-lhe, no exercício de suas atribuições, encontrar os meios adequados para fazer cumprir os preceitos legais pertinentes.

Observe-se, neste passo, que o não atendimento, por qualquer razão, do direito fundamental à saúde de um cidadão, mais que uma ilegalidade, denota grave violação da própria Constituição Federal.

No plano fático, tem-se um portador de patologia já crônica, a necessitar dos medicamentos indicados, sob pena de sofrer ainda mais riscos na sua qualidade de vida, como comprovam os documentos que instruíram o pedido.

A fundamentalidade do direito à saúde e à existência de uma vida digna exige um sério enfrentamento em sede doutrinária, jurídica e jurisprudencial. É, portanto, o que se faz.

A Constituição de 1988, ao legitimar o Poder Judiciário no artigo 2º, em conformidade com o parágrafo único do artigo 1º, diretamente nos termos desta Constituição – por vontade expressa do Constituinte originário, como representante da soberania popular- impôs a difícil tarefa de ser o garantidor dos direitos fundamentais ali inseridos, de cunho altamente complexos e subjetivos, contra qualquer tentativa de usurpação ou violação, tanto pelo Estado quanto pelos particulares.

Ocorre que a matéria ora ventilada encontra-se na difícil tarefa de acomodação entre o sistema de garantias jurídicas e o sistema econômico Estatal, ou seja, jaz na árdua missão de buscar a equidade entre a gama de direitos positivados no plano abstrato, com a devida realidade fática da sociedade brasileira.

Considerando que o Direito em si não é uma ciência descritiva, pois trabalha com conceitos que têm por objeto valores éticos, políticos e uma série de fenômenos sociais, faz-se mister que a ciência jurídica destaque a relevância de todos os fatores essenciais à compreensão de seus novos conteúdos, para proceder uma leitura a partir de sua conexão com o todo, de uma perspectiva sistemática. Assim, trata-se de não repetir o erro que condenou à superação o sistema tradicional de interpretação e o conceito estritamente positivista do Direito: o de confundir uma lógica formal, quando se trata de uma unidade valorativa material[1].

Outro relevante aspecto que requer menção reside no fato da inadmissibilidade de, em pleno século XXI, se pensar em uma interpretação literal dos ditames legais. Resta superada a ideia estritamente positivista da aplicação do método da subsunção da escola de Savigny, necessitando-se, pois, de métodos concretizadores e de um olhar sistemático ao conjunto de regramentos positivados, bem como com a realidade que o mesmo pretende acompanhar e regular.

Os direitos fundamentais, em rigor, não se interpretam; concretizam-se. A metodologia clássica da Velha Hermenêutica de Savigny, de ordinário aplicada à lei e ao Direito Privado, quando empregada para interpretar direitos fundamentais, raramente alcança decifrar-lhes o sentido. Os métodos tradicionais, a saber, gramatical, lógico, sistemático e histórico, são de certo modo rebeldes a valores, neutros em sua aplicação, e por isso mesmo impotentes e inadequados para interpretar direitos fundamentais. Estes se impregnam de peculiaridades que lhes conferem um caráter específico, demandando técnicas ou meios interpretativos distintos, cuja construção e emprego gerou a Nova Hermenêutica. (...) Com efeito, na Velha Hermenêutica *interpretava-se* a lei, e a lei era tudo, e dela tudo podia ser retirado que coubesse na função elucidativa do intérprete, por uma operação lógica, a qual, todavia, nada acrescentava ao conteúdo da norma; em a Nova Hermenêutica, ao contrário, *concretiza-se* o preceito constitucional, de tal sorte que concretizar é algo mais do que interpretar, é, em verdade, interpretar com acréscimo, com criatividade. Aqui ocorre e prevalece uma operação cognitiva de valores que se ponderam. Coloca-se o intérprete diante da consideração de princípios, que são as categorias por excelência do sistema constitucional[2].

Muito embora estejamos sob a égide do fenômeno da força normativa da Constituição, quando os princípios constitucionais deixam o plano metafísico, valorativo e passam a adquirir condição normativa, podendo diretamente ser reclamados e aplicados via jurisdição, também se sabe que a Constituição não tem existência autônoma frente à realidade que pretende retratar. Häberle diz: *"La realidad jurídica del Estado constitucional representa solo uma parte de la realidad de uma Constituición viva, que, em profundidad, és de natureza cultural. Los textos constitucionales deben ser literalmente cultivados para que resulten uma Constitución[3]".*

Nesse contexto, Bobbio aponta o cerne da questão: "O problema fundamental em relação aos direitos do homem, hoje, não é tanto o de justificá-los, mas o de protegê-los. Trata-se de um problema não filosófico, mas político[4]". Diante de tal afirmação, pode-se verificar que o efetivo cumprimento dos direitos fundamentais depende basicamente do cumprimento da política adotada pela forma de Estado, no caso, a forma democrática, prevendo não somente a participação dos cidadãos no processo decisório, como também sendo o instrumento para a realização de valores essenciais à convivência humana em sociedade.

Não basta enumerar, definir, explicitar, assegurar só por si direitos fundamentais; é necessário que a organização constitucional esteja orientada para a sua garantia e sua promoção. Assim como não basta afirmar o princípio democrático e procurar coincidência entre a vontade política do Estado e a vontade popular, em qualquer momento; é necessário estabelecer um quadro institucional em que esta vontade se forme em liberdade e que cada cidadão tenha a segurança da previsibilidade do futuro[5].

Discorridas as questões meramente iniciais em nível de esclarecimento hermenêutico, passa-se ao enfrentamento à problemática da efetivação do direito fundamental a saúde em sede de jurisdição constitucional, apontando os pontos basilares à compreensão do tema, que servem de subsídio à fixação da convicção formada, pertinente a esta matéria.

O direito alegado pela parte encontra respaldo legal na tutela do direito à saúde constitucionalmente consagrada em seu art. 6º, complementado, especialmente, pelo artigo 196, dizendo que: *"garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."*

O constituinte federal de 1988 orientou sobremaneira a precisão do conceito de saúde, tendo em várias hipóteses elucidado o seu conteúdo. Assim, saúde implica uma definição de política pública que vise seu cuidado, sua defesa e sua proteção (CF, art. 23, II e 24, XII), ou seja, reforça-se, como requisito da legalidade, a obrigação de prestar serviços de atendimento à população (CF, art. 30, VII) que incluam ações para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Também o educando foi lembrado ao se esclarecer que o conteúdo de conceito constitucional de saúde deve garantir-lhe a assistência

sanitária (CF, art.208, VII); como deve ser igualmente, assegurado à criança e ao adolescente, com programas de assistência integral à saúde, para o que é exigida a aplicação de um percentual dos recursos destinados à saúde para a assistência materno infantil (CF art.227, § 1º, I)[6].

Ainda, cabe frisar, que o conceito de saúde adotado pela OMS (Organização Mundial da Saúde) enseja um conteúdo muito mais amplo do que a mera integridade física, qual seja: ***"A saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental, social e não apenas a ausência da enfermidade".***

Partindo do conceito de saúde aceito pela própria OMS, que chamei de *conceito oficial,* não é difícil demonstrar o quanto nossa Constituição Federal buscou preservar esse importante interesse, que é de cada um dos indivíduos, e indivisivelmente, de todos. A partir da peculiar forma de tutela constitucional da saúde, conforme destaco logo abaixo, obviamente o legislador infraconstitucional seguiria pelo único caminho possível, o de dar complemento a essa tutela – reforçando - na maioria das vezes – aspectos que tratam das formas de preservar a saúde pública de atividades que venham a afrontá-la[7].

Por conseguinte, rebato uma vez mais, qualquer argumento que exima qualquer das esferas instituídas da responsabilidade para com a prestação deste conceito amplo de saúde. A Constituição, além de prever em seu artigo 198 a competência comum, no sentido que todos os entes públicos atuem no campo da saúde pública, também determinou que todos integram uma rede regionalizada e hierarquizada, constituindo assim o Sistema Único de Saúde.

A hierarquização mencionada no artigo 198 da CF, mal compreendida na área do direito, é termo técnico, do setor de saúde significando *divisão de serviços em nível de complexidade crescente;* assim, um serviço primário, ao deparar-se com um paciente exigente de atenção mais complexa, deve saber para onde tal paciente deve ser encaminhado. É a referência e a contra-referência: o paciente tem acesso aos serviços de saúde através de um serviço de menor complexidade, devendo ser referenciado para os serviços de maior complexidade na medida de suas necessidades individuais (excetuadas as situações emergenciais). É a hierarquização de serviços em nível de complexidade crescente. A regionalização pressupõe a hierarquização e aí os serviços se imbricam (dentro do conceito de rede): serviços municipais e serviços estaduais (raramente federais, pois a união não mais executa os serviços médico-hospitalares) devem atender, muitas vezes a um mesmo paciente, dependendo da complexidade da sua doença, e o atendimento que se iniciou em um serviço municipal, deverá prosseguir em um serviço estadual, referenciado pelo municipal[8].

A atuação conjunta e coordenada no campo da saúde é uma imposição constitucional de prestação solidária deste direito. Veja-se:

> ***APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO (DIREITO À SAÚDE). AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 1. A promoção da saúde constitui-se em dever do Estado, em todas as suas esferas de Poder, caracterizando-se a solidariedade entre União, Estados e Municípios, inviabilizando a tese de ilegitimidade passiva ad causam do Estado do Rio Grande do Sul. Exegese dos arts. 5º, XXXV e 196, ambos da Constituição Federal. Precedentes desta Corte. 2. Comprovada a necessidade de realização de exame para constatação do problema de saúde que acomete a postulante, em razão de apresentar fortes dores, bem como a sua insuficiência financeira em arcar com tal despesa, sem prejuízo do próprio sustento, é de ser acolhida a pretensão. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70026695080, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em 13/11/2008)***
>
> ***APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO (DIREITO À SAÚDE). AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 1. Diante da regra inscrita no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, não há que se falar em esgotamento da via administrativa como condição para postular judicialmente o fornecimento de medicamentos. 2. A promoção da saúde constitui-se em dever do Estado, em todas as suas esferas de Poder, caracterizando-se a solidariedade entre União, Estados e Municípios. Exegese do artigo 196, da Constituição Federal. Precedentes desta Corte. 3. Comprovadas a enfermidade e a necessidade dos medicamentos, bem como a insuficiência financeira do postulante a arcar com tal despesa, sem prejuízo do próprio sustento, é de ser acolhida a pretensão. 4. O Estado está isento do pagamento das custas judiciais a Cartório Judicial Privatizado, com fulcro no parágrafo único, do art. 11, da lei 8.121/85. 5. Honorários ao Defensor Dativo. Possibilidade. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO DESPROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE EM REEXAME NECESSÁRIO. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70019868678, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS.)***

Nesta esteira, caberá às três esferas de repartição de competência, respeitada a dotação orçamentária destinada em conformidade com o número de atendimentos e verbas de cada ente federativo, a obrigação do poder público para com o atendimento ao direito fundamental à saúde.

O direito à saúde remonta à compreensão do mesmo enquanto um direito fundamental de segunda dimensão, característico do impacto causado pela industrialização e os graves problemas econômicos e sociais que acompanharam este processo, podendo-se perceber que apenas o reconhecimento formal dos direitos de igualdade e de liberdade não é suficiente para garanti-los aos cidadãos. Para tanto, exigiu-se do Estado uma posição efetiva para minimizar os problemas sociais, daí seu caráter de dimensão positiva. Segundo as lições de Bonavides:

Os direitos sociais fizeram nascer à consciência de que tão importante quanto salvaguardar o indivíduo, conforme ocorreria na concepção clássica dos direitos de liberdade, era proteger a instituição, uma sociedade muito mais rica e aberta à participação criativa e a valoração da personalidade que o quadro tradicional da solidão individualista, onde se formara o cunho liberal do homem abstrato e insulado, sem a densidade dos valores existenciais, aqueles que unicamente o social proporciona em toda a plenitude[9].

Muitas são as discussões doutrinárias acerca do modelo de direitos fundamentais sociais, como sendo direitos fundamentais. Sem aqui incorrer no mérito de analisar as várias divergências acerca do tema, ressalto apenas o modelo proposto por Robert Alexy baseado no sopesamento. Este modelo, determina a fundamentabilidade baseada em um modelo *prima facie,* que diz respeito aos direitos que à primeira vista os cidadãos poderão exigir em relação ao Estado, especialmente, os que concretizem direitos de liberdade e dignidade humana. A *posteriori*, é na estrutura argumentativa, com

a apresentação das razões e das contra razões jurídicas e fáticas, que se irá extrair os direitos que necessitam ser imediatamente aplicáveis, da mesma forma que ocorre com as normas de direitos fundamentais[10]. O que me parece um tanto certo, no tocante à aplicação do direito à saúde.

Luis Roberto Barroso, embora reconheça expressamente o alto grau de dificuldade na efetivação dos direitos sociais, que se apresenta por deveras mais complexa que as demais categorias, diante dos empecilhos de ordem econômica e de caráter político na sua realização, acredita não poder mais prosperar a alegação de falta de juridicidade destes direitos. Afirma que a resistência que se apresenta à efetivação destes direitos via coercitiva é de caráter muito mais ideológico do que propriamente jurídico[11].

Com efeito, cumpre-nos referir que em face da fundamentalidade que alguns direitos sociais abarcam em seus conteúdos vinculando a atuação positiva do Estado na implementação de um patamar material mínimo a propiciar condições para uma vida digna, não é crível que se outorgue outro tratamento se não o mesmo destinado às normas de direitos fundamentais – de onde se extrai a conclusão que alguns direitos sociais- fundamentais, gozam da eficácia imediata expressa no artigo 5º, § 1º da Carta Magna, impondo ao Estado o dever de otimização e concretização destes dispositivos plenos em seus conteúdos. Hodiernamente, aos que opinam que as mesmas somente seriam exigíveis a partir da criação pelos poderes instituídos de programas e regulamentações, concretizações legislativas, rebate-se qualquer argumento, em que pese o caráter programático[12] dessas normas, pois diante de seu conteúdo essencial mostram-se direitamente aplicáveis pelo Poder Judiciário.

Independentemente – ainda – da discussão em torno da possibilidade de se reconhecerem direitos subjetivos à prestação, com base em normas de cunho eminentemente *programático* (para nos mantermos fiéis às terminologias adotadas), importa ressaltar mais uma vez que *todas as normas consagradoras de direitos fundamentais são dotadas de eficácia e, em certa medida, diretamente aplicáveis já ao nível da constituição e independentemente de intermediação legislativa*. Em verdade, [...] todas as normas de direitos fundamentais são direta (imediatamente) aplicáveis na medida de sua eficácia[13].

A Constituição de 1988 inovou na terminologia ao referir a existência de serviço de relevância pública, o que é diferente de serviço público. Quis o legislador dar especial atenção à manutenção e fiscalização deste serviço, em face da relevância social das ações e serviços de saúde, como dispõe o artigo 197, II, da Constituição Federal, devendo sua execução ser feita tanto através do Estado, ou através de terceiros, bem como por pessoa física de direito privado. Significa que, existindo um confronto com outro serviço que não tenha a qualificação de relevância pública, o administrador público deverá privilegiar o direito à saúde, como, por exemplo, na destinação de recursos. Dessa forma, a Constituição veda a inversão de prioridades por parte do administrador no exercício de sua função pública.

Contudo, não pode o intérprete constitucional ficar alheio à realidade fática que o toca na práxis jurídica, em que não raras vezes a concretização do direito à saúde encontra um óbice na questão orçamentária.

Obviamente que os direitos fundamentais exigem máxima e imediata efetivação dos poderes constituídos, no entanto, não há sequer um direito fundamental no ordenamento jurídico que se encontre como absoluto, ou seja, na sua aplicabilidade, os direitos fundamentais estarão sujeitos a restrições. Papel este que incumbe ao intérprete constitucional na análise da demanda pleiteada pelo cidadão.

Dito isto, não pode prosperar a retórica de que o judiciário estaria interferindo em uma esfera que competiria ao poder executivo, quer dizer, a opção pelas políticas públicas a serem implementadas. Quando o judiciário interfere determinando a garantia de um direito fundamental a ser reclamado frente à jurisdição, não está realizando outra tarefa senão a incumbida pelo constituinte originário – a de resguardar os direitos e de garanti-los sempre que um for violado ou estiver em iminente perigo. Obviamente, quando uma demanda que se refere à saúde chega ao conhecimento da jurisdição constitucional, não pode o judiciário abster-se em julgá-la e, menos ainda, em julgá-la em desconformidade com a Constituição.

Embora se reconheça que é na esfera legislativa e a executiva o local apropriado à concretização das políticas públicas sociais, mais uma vez, ressalto: não pode o Judiciário eximir-se desta demanda, uma vez que, presume-se que somente recorre-se à jurisdição quando não se obteve êxito na satisfação de sua necessidade. De outra banda, cabendo à jurisdição proclamar uma resposta ao feito - o que deve se esperar deste poder - indiscutivelmente, é uma decisão que considere todos os elementos envoltos, fundamentada racionalmente na tentativa de acomodação do texto da norma com o contexto social.

Diretamente vinculada a esta característica dos direitos fundamentais sociais a prestações, encontra-se a problemática da efetiva disponibilidade de seu objeto, isto é, se o destinatário da norma se encontra em condições de dispor da prestação reclamada (isto é, de prestar o que a norma lhe impõe seja prestado); portanto, na dependência da real existência dos meios para cumprir com sua obrigação. Já há tempo se averbou que o Estado dispõe apenas de limitada capacidade de dispor sobre o objeto das prestações reconhecidas pelas normas definidoras de direitos fundamentais sociais, de tal sorte que a limitação dos recursos constitui, segundo alguns, em limite fático à efetivação destes direitos. Distinta da disponibilidade efetiva dos recursos, ou seja, da possibilidade jurídica de disposição, situa-se a problemática ligada à possibilidade jurídica de disposição, já que o Estado (assim como o destinatário em geral) também deve ter a capacidade jurídica, em outras palavras, o poder de dispor, sem o qual nada lhe adiantam os recursos existentes.

Encontramo-nos, portanto, diante de duas facetas diversas, porém intimamente entrelaçadas, que caracterizam os direitos fundamentais sociais prestacionais. Nesta árdua tarefa de encontrar o equilíbrio entre o valor orçamentário destinado a sua realização e as demandas propostas no exercício da cidadania propiciado com acesso à justiça a qualquer cidadão para tutela do seu direito, urgem teorias e argumentos como a reserva do possível.

É justamente em virtude destes aspectos que se passou a sustentar a colocação dos direitos sociais a prestação sob o que se denominou de uma 'reserva do possível', que, compreendida em sentido amplo, abrange tanto a possibilidade, quanto o poder de disposição por parte do destinatário da norma. Em verdade, a reserva do possível é uma composição doutrinária, geralmente invocada quando da necessidade de prestação de um direito fundamental, mais propriamente, um direito fundamental social, que *a priori*, seriam os quais exige uma ação positiva, prestação de um serviço do Estado para com seus cidadãos.

Segundo doutrinador português Canotilho[14], a efetivação dos direitos sociais deve estar pautada na "reserva do possível" estando estes atrelados aos recursos econômicos. Qualquer elevação ou maior disposição desses direitos estaria atrelada ao volume possível de recurso a ser conseguido com verbas públicas.

Tal doutrina propriamente originária do direito constitucional alemão e bem recepcionada em muitos países europeus, não pode em hipótese alguma ser recepcionada da mesma forma em países de modernidade tardia como o Brasil, que sequer consegue garantir o mínimo vital, ou seja, às condições de mantença da vida humana, quiçá lá, da vida humana com dignidade.

Não é crível pensar que tal argumento prospere nestes países europeus, quando a demanda se referir a manutenção da vida dos seus cidadãos, ou seja, o direito fundamental à saúde. Outros direitos sociais poderão respeitar com muito mais rigor as dotações orçamentárias como é o caso do direito ao lazer, a cultura, em que é possível uma programação da destinação dos seus recursos. Não há como prever, de forma rigorosa quantos são os pacientes a necessitar de internação de um leito pelo SUS ou de uma medicação indispensável à sua saúde.

Como na prática não há como fugir da restrição destes direitos, necessário se faz a criação de limites e restrições concentrando-se nas condições sociais, econômicas e culturais da sociedade brasileira, pois a importação de uma teoria cuja realidade fática é gritantemente diferenciada de nossas condições reais, poderá gerar danos irreparáveis a concretização constitucional.

O fato de admitir que a reserva do possível é imposto por uma limitação fática por falta de recursos, escassez de verbas que deveriam os poderes públicos dispor para o cumprimento dos direitos sociais prestacionais, assim como há também uma limitação o qual se pode denominar jurídica, pois se refere à dotação em matéria orçamentária prevista em sede orçamento anual decorrente de destinação por via legislativo-parlamentar; também em aponto e indispensável, reconhecer a existência de um núcleo de direitos e necessidades humanas que clamam por emergente efetivação sob pena de extinguir-se a própria vida do cidadão reclamante. A esses direitos, que se referem à saúde, integridade física e mental, que são pressupostos para o exercício da dignidade da pessoa humana, o argumento da reserva do possível não pode prosperar[15].

Ressalva se faz, quanto ao argumento da reserva do possível, no que se referir à reserva que o indivíduo pode razoavelmente exigir da sociedade. Neste argumento, mesmo que o Estado dispusesse de tais recursos, não seria ele obrigado à sua prestação, pois não estaria dentro do arcabouço material que a sociedade espera que o Estado preste. Portanto, ressalto mais uma vez, que o argumento que deve prosperar é referente ao aplicação do princípio da proporcionalidade, que necessita do intérprete a análise do caso concreto, que a posteriori será enfrentado.

Em nenhum momento a doutrina constitucional nega a existência de limitação de verbas públicas, contudo, reconhecer deste argumento para que quando provocada a jurisdição constitucional para dar garantia das normas de direito social consagrada, mais propriamente, as que se referem à manutenção da saúde, é como dar um aval aos poderes públicos para aplicar os recursos financeiros em ações que possam se reverter em maiores vantagens eleitoreiras. Seria um pouco negar da a essencialidade da manutenção da saúde para o próprio exercício da cidadania. Na mesma seara de argumentação Silva:

Uma fragilidade inicial do argumento da escassez econômica, sob o aspecto jurídico, refere-se ao fato de ter a Constituição deferido aos entes da federação competências tributárias e financeiras, as quais seriam fonte eficiente para a arrecadação de recursos destinados à implementação das políticas públicas pertinentes aos direitos fundamentais prestacionais, desde que, evidentemente, feridos com êxito e racionalidade os recursos obtidos. Contudo, a mansidão que os entes públicos demonstram na aceitação do não-pagamento de seus créditos, frustra o plano constituinte de administração econômica das finanças públicas. (...) Mesmo nas hipóteses mais complexas, em que postulem decisões definitivas e profundas, como por exemplo, a criação de leitos públicos de atendimento de saúde materno-infantil em município desprovido de qualquer maternidade pública, ainda aqui a cláusula de escassez apresenta pertinência relativa, eis que há possibilidade de fixação de obrigação orçamentária para exercício subsequente.

Ainda na mesma linha de retórica, Galdino[16]:

(...) o que efetivamente frustra a efetivação de tal ou qual direito reconhecido como fundamental não é a exaustão de um determinado orçamento, é a opção política de não se gastar dinheiro com aquele mesmo direito. O argumento de exaustão orçamentária" presta-se unicamente a encobrir as escolhas trágicas que deixaram de fora do universo do possível a tutela de algum direito.

Daí que se observa que dois fatores são decisivos à inefetividade dos direitos sociais prestacionais: um de natureza meramente material, frente a escassez de recursos públicos para o custeio destes direitos, e outro de caráter ideológico, político, que falta de disposição política para realização destes direitos, momento em que os poderes ficam discutindo acerca do que compete a cada um dentro das suas competências e do limite de sua atuação, ao invés de somarem esforços na realização destes direitos.

Os aportes financeiros e econômicos à concretização dos direitos fundamentais certamente constituem um impedimento fático e real, diante da falta de recursos, escassez de verbas que deveriam os poderes públicos dispor para o cumprimento dos direitos sociais prestacionais; bem como, existe também uma limitação de "jurídica", referente à dotação em matéria orçamentária prevista em sede orçamento anual decorrente de destinação prevista pelo poder executivo e legislativo.

Acerca do tema, Silva manifesta sua contrariedade a tais argumentos, na medida em que vislumbra o risco desta retórica a efetividade dos direitos sociais-fundamentais:

As limitações fáticas do Estado para a consecução dos direitos fundamentais prestacionais passaram a ser categorizadas como cláusula da *reserva do possível*, oponível na sua atualidade, segundo o pensamento mais tradicional, contra toda e qualquer concretização jurisdicional dos direitos prestacionais. Assim, a universalização do argumento da reserva do possível passou a constituir mais um óbice para a efetividade dos direitos a prestação, eis que o argumento findou por fazer coro ao já sonoro refrão da inefetividade das normas constitucionais, servindo frequentemente a inconfessáveis objetivos de frustração da vontade constitucional de transformação da realidade brasileira na direção da inclusão social[17].

Sem adentrar no mérito do problema, resolve-se tal argumento de uma lógica por deveras conhecida a realidade jurídica brasileira o qual não permite prosperar a ideia da reserva do possível muito bem desenvolvida na doutrina europeia que não condiz com a pluralidade da realidade social brasileira: todos os Estados brasileiros vivem em *déficit* orçamentários. Os recursos destinados nas leis orçamentários compõem o que se poderia chamar de mínimo vital para a mantença da própria garantia formal destes direitos.

Ainda, sem considerar o mérito que rebate tal argumento: a que a reserva do possível deveria limitar-se ao ponto de não afetar a dignidade da pessoa humana. Conforme alude Silva[18]:

A identificação dos conteúdos matérias da dignidade da pessoa humana coincide com a construção acerca das condições da liberdade (a liberdade para) ou a igualdade de chances. Os direitos de liberdade, inicialmente compreendidos apenas em sua dimensão negativa, significando "o poder de autodeterminação do indivíduo, a liberdade de ação ou omissão sem qualquer constrangimento por parte do Estado", passaram a ser lidos também na sua significação positiva, identificada com os direitos do mínimo existencial, com o direito "às condições mínimas de existência humana digna que não pode ser objeto de intervenção do Estado e que ainda exige prestações positivas". A categoria do *mínimo existencial* refere-se, portanto, à dimensão essencial e inalienável dos direitos da pessoa, inclusive dos direitos que demandam prestações estatais. Assim, no que tange aos níveis primários e essenciais, pressupostos para o exercício de liberdade e todas as pessoas e para a garantia da igualdade de oportunidades, os direitos à saúde, à educação, à assistência social, ao acesso a justiça e à moradia/abrigamento se converterem em direitos fundamentais de liberdade, está compreendida como liberdade para ou igualdade de chances.

Em suma, para efetivar a dignidade da pessoa humana deve-se garantir um mínimo existencial, ou seja, um núcleo material e social que não permita que os indivíduos se encontrem em situação indigna. Por óbvio, a situação sócio-econômica de cada cidadão é diferente, e cabe ao Estado igualar às condições necessárias para a manutenção da dignidade dos seus.

O novo paradigma que justifica a forma de normatização do Direito à saúde na CF/1988, refere-se justamente como sendo este direito indispensável ao conceito de dignidade da pessoa humana, vez que sem a primazia deste direito põe-se em risco a vida humana, quem dirá a vida com dignidade:

Assim, aconteceu com diversos direitos fundamentais, esse conteúdo de saúde acaba por demonstrar parcial e insuficiente para satisfazer as necessidades da pessoa humana e a construção de uma sociedade com reduzida desigualdade social (objetivos do Estado social). O individualismo do enfoque não atende os anseios de promoção da saúde e, nem mesmo de garantia de permanência sadia. Ambos dependem de forma marcante da qualidade de vida comunidade. Com efeito, ainda que premiado a visão individual, o cidadão não poderá continuar saudável sem o meio em que vive – e as pessoas que o rodeiam – também estejam ou possuam condições de salubridade, especialmente diante de contágio e da contaminação pelos agentes diretamente provocadores de doença. (...) Logo, a saúde deve ser examinada – e tutelada –no contexto do ambiente circundante – O mundo exterior e as influências sobre a vida humana adquirem relevância, especialmente dos trabalhadores. A preocupação é antes de tudo com a prevenção dos males, mediante a garantia de condições de vida digna a população, sob uma visão social e coletiva[19]. (p.120)

Não restam dúvidas que na prática, por mais imperioso que seja o direito à saúde e à manutenção da vida digna, o mesmo sofrerá restrições. Contudo, não sob a alegação da reserva do possível, por todos os elementos alhures referido; deverá sim, o intérprete face ao caso concreto e através dos seus elementos fáticos proceder o sopesamento, a ponderação dos interesses contrapostos em jogo, visando proceder à decisão mais equitativa possível. Restringir este direito no caso concreto, não é o mesmo que alegar não o conceder em face de não haver previsão orçamentária, é simplesmente atuar de forma responsável, visando a aplicabilidade das normas jurídicas dentro do sistema normativo, que encontra obstáculos entre seus próprios conteúdos muitas vezes conflitantes entre si, na sua concordância prática e na máxima efetivação de um direito fundamental que inúmeras vezes choca-se que a máxima efetivação do mesmo direito de outrem.

Senão, vejamos:

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. Independentemente de situar a obrigação ao fornecimento de medicamentos como condição da ação ou matéria de mérito, os entes públicos, por força de normas através das quais se organizou o Sistema Único de Saúde, assumiram cada qual certas responsabilidades, conforme previsto na Lei nº 8.080/90 e nas NOB-SUS 01/96 e 01/02. Salvo hipóteses excepcionais, de risco de vida, a responsabilidade do Estado do Rio Grande do Sul passa pela disciplina das Portarias nº 2.577/06, do Ministério da Saúde, nº 238/06, da Secretaria de Saúde, e da Lei-RS nº 9.908/93. O fornecimento de fármacos não listados nessas relações não é imputado aos órgãos públicos de saúde, em respeito ao planejamento da distribuição de recursos elaborado pelo Poder Executivo, visando ao menor gasto com o alcance dos fins estipulados, pois, do contrário, beneficiar-se-ia o indivíduo em detrimento da grande massa de necessitados. A análise da pretensão inicial não prescinde do cotejo entre a necessidade individual e os custos resultantes para o Poder Público e para a sociedade, sob pena de romper-se o princípio da isonomia ao se conceder tratamento diferenciado à parte autora, enquanto outros necessitados aguardam a satisfação do fornecimento dos medicamentos de que precisam. A justiça distributiva é uma forma de justiça que ordena o bem comum e o fundo social comum ao particular. Os interesses particulares devem ser ordenados de tal modo que seja possível a vida com liberdade de maneira proporcional, propiciadora do bem comum. No processo em que ausente prova suficiente, não se admite a

superação dessa realidade, por aplicação do princípio da proporcionalidade. APELO PROVIDO. VOTO VENCIDO EM PARTE. (Apelação Cível Nº 70023678675, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rejane Maria Dias de Castro Bins, Julgado em 28/08/2008)

Estes são fatores reais que o Direito não pode deixar de enfrentar e democratizar o debate, pois a intenção é que o intérprete da Constituição venha a refletir os anseios da população, propiciando força aos conteúdos constitucionais.

Ocorre que, o juízo de ponderação que irá em caso concreto impor "um limite/restrição" a um direito fundamental, também está moldado por limites impostos para a máxima da mínima afetação de um direito fundamental mediante a proteção do seu núcleo essencial dos direitos fundamentais que não deve ser afetado sob pena de esvaziar a sua totalidade[20]. Será através da ponderação e da aplicabilidade do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, que poderá mensurar os limites e restrições a estes direitos numa relação de custo/benefício.

Visto a importância e a imprescindibilidade do referido princípio para a efetividade dos direitos fundamentais no Estado Democrático de Direito, impende elucidar os três critérios (deveres) essenciais para o juízo da proporcionalidade.

O princípio da proporcionalidade, enquanto restrição externa de um direito fundamental, desdobra-se em três dimensões que deverão ser rigorosamente respeitadas, a fim de não ultrapassar os limites dos limites e das restrições (e passar a ser uma medida arbitrária ao invés de uma justificação aos limites e restrições de direitos fundamentais). Trata-se, primeiramente do <u>dever de adequação do meio</u>, exige que no caso concreto se verifique se o fim é legítimo, se era o meio mais adequado, apto, útil e idôneo, no sentido de atingir a finalidade pretendida; <u>dever de necessidade</u> requer a adoção do meio menos gravoso, que a utilização deste meio proporcionou menos desvantagens e afetação a um direito fundamental, seus resultados trazem menores prejuízos; e, por fim, <u>dever de proporcionalidade em sentido estrito</u> que é a análise da relação custo/benefício, obtida através da análise entre o resultado obtido pelo emprego do meio eleito e a afetação desvantajosa dele decorrente aos direitos fundamentais – atendendo outrora também o princípio da concordância prática[21].

Salienta-se a imprescindibilidade da correlação e da ordem dos três elementos ou parciais da ponderação, na medida que uma resposta não condizente, condicionada e invalidade a aplicação do princípio da proporcionalidade, na medida em que passará a não justificar a restrição de um direito fundamental. Além disso, [22]**,** interpretando o comando da econômica do Estado declina que:

Quando se afirma que o Poder Executivo é que detém a responsabilidade pela efetivação do direito à saúde garantido constitucionalmente e infraconstitucionalmente, na verdade, quer-se dizer que ele é responsável, juridicamente, pela dimensão operacional dessa efetivação – sua possibilidade pragmática-, haja vista que tem a incumbência de gestar o plexo do orçamentário (plurianual, diretrizes e orçamento anual) que se destina a isso, devidamente aprovado pelo Parlamento de cada entidade federativa (notadamente as prioridades públicas neste nível transmutadas em rubricas orçamentárias a serem executadas) (...).Por isso é que cada demanda de saúde submetida ao Estado é merecedora de uma apreciação e ponderação em face de, no mínimo, duas variáveis necessárias: (a) a variável qualitativa-normativa-constitucional (e infraconstitucional), enquanto direito fundamental assegurando à sociedade brasileira e compartida dentre todos os atores envolvidos; (b) a variável quantitativa-orçamentária, em face das possibilidades materiais limitadas do atendimento de demandas cada vez mais ilimitadas.

Por derradeiro, ao considerar às condições econômicas do Estado, antes de condená-lo ao pagamento desta demanda, faz-se mister a análise das condições financeiras do requerente e, não somente deste, mas do grupo familiar que o cerca.

Porque não, em se considerando o caso *in concreto*, partir para análise da possibilidade econômica dos ascendentes e descendentes e, ainda, da análise das condições financeiras de prestar o pedido da demanda dos colaterais – visto que, por analogia, poder-se-ia fazer referência ao código civil na previsão no tocante ao dever de alimentos por parênteses, como discorre o art. 1695 do código civil.

Tornar-se-ia plenamente possível em se considerando a dimensão horizontal dos direitos fundamentais – a qual se assenta na ideia que os direitos fundamentais podem ser requeridos também nas relações inter privadas. Nesta retórica, a tutela dos direitos individuais nas relações entre particulares não se esgota na garantia de uma obrigação geral de abstenção, nem na reparação de danos através da responsabilidade civil.

Ela envolve uma tutela preventiva de direitos com uma atuação repressiva e corretiva, bem como obrigações negativas e positivas dos particulares, dependendo das circunstâncias do caso concreto. Obviamente, os direitos fundamentais nas relações inter privadas não teriam a mesma força e incidência como decorre da relação do Estado para com seus cidadãos, mas em se tratando de Estado democrático de Direito, o princípio da solidariedade deverá se fazer presente, mesmo em ações positivas que gerem certos custos aos obrigados, como por exemplo, já ocorre em relação à função social e agora se fala em função ambiental da propriedade privada.

Além disso, se os direitos sociais são também fundamentais e se a dignidade da pessoa humana é reconhecida a qualquer pessoa (de tal sorte que também, mesmo com base numa leitura minimalista-liberal, os direitos relacionados ao mínimo existencial são a atribuídos a todos e a qualquer um) não há como sustentar uma exclusão dos direitos sociais no que diz a vinculação dos poderes públicos e dos próprios particulares, sem que com isso se esteja a desconsiderar possíveis e até mesmo necessárias diferenciações quanto ao modo de vinculação[23].

Pensando-se na aplicação do princípio da proporcionalidade muitos são os elementos a ser considerado na análise do caso em tela, seja pela condição física e financeira do requerente, seja pela possível restrição a um direito individual frente a um direito coletivo, seja pela eficácia irradiante dos direitos fundamentais, que não comprometem apenas o Estado na sua tarefa de concretização, mas uma tarefa também dirigida aos particulares.

Ademais, sobreleva anotar que o laudo médico juntado pela parte autora é esclarecedor em relação à imprescindibilidade do tratamento, *in verbis:*

"A paciente Carine Toebe em dezembro de 2020 foi diagnosticada com neoplasia de cólon metastática para o fígado, patologia classificada sob o CID10 COMO C18. A análise do perfil molecular do tumor demonstra KRAS e NRAS selvagens. Realizou ileocolectomia radical direita em março de 2021 seguida de 2 cilos de quimioterapia com FOLFOX seguidos de segundo tempo de hepatectomia em agosto de 2021. Permaneceu em quimioterapia com FOLFOX desde então até o início do mês de novembro de 2021. Realizou tomografias de reavaliação sistêmica que evidenciam o surgimento de ascite, espessamento peritoneal e nódulos pulmonares sugestivos de progressão da doença. Tendo em vista a progressão da doença em vigência de quimioterapia com FOLFOX, a paciente tem indicação de mudança de tratamento quimioterápico. Iniciou a quimioterapia com FOLFIRI. Contudo, por se tratar de um tumor com KRAS e NRAS selvagens, tem indicação formal de de associação de Cetuximabe (Erbitux®) 500mg/m2, endovenoso, a cada 2 semanas, por tempo indeterminado, até progressão de doença ou toxicidade limitante."

Ademais, restou demonstrada a necessidade da medicação em particular, pois não há alternativa terapêutica equivalente à solicitada liberada pelo SUS. Assim refere a médica da autora: "*a história natural da neoplasia, quando não tratada com terapias que possam potencialmente alterar seu prognóstico, cursa com complicações clínicas graves que incluem a piora do sensório, déficit motor e cognitivo e disfunção de órgãos vitais",* E17, OUT3.

À vista disso, a prova produzida indica a existência da patologia e a necessidade do tratamento pleiteado, sendo que os documentos que instruem a inicial demonstram a incapacidade financeira da autora para arcar com os custos do tratamento de alto orçamento, não havendo o que falar em necessidade da autora juntar outros documentos que atestem (reiterem) o que já foi demonstrado.

O fato do atestado médico ter sido obtido por meio de consulta que não se operou pela rede pública demonstra, no presenta caso, a urgência do documento técnico a embasar a celeridade no tratamento pelo sistema público, atestado pela médica que a assistiu, que ressaltou o elevado risco de óbito. Outrossim os exames patológicos e demais foram realizados pelo SUS, E17, não se extraindo dessa situação capacidade financeira.

Ao exposto, **JULGO PROCEDENTE** a pretensão civil para, tornando definitiva a tutela provisória de urgência antecipatória, determinar ao Estado do Rio Grande do Sul que forneça à parte autora o medicamento *Cetuximabe (Erbitux)* 5mg/ml, na quantidade indicada pelo médico, conforme prescrição juntada pela parte autora (E1, LAUDO8, fl. 3).

O requerido deverá ser intimado para, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, comprovar a disponibilização do medicamento ao autor, sob pena de bloqueio de valores.

Fixo a multa diária pelo descumprimento, no montante de R$ 100,00 (cem reais).

Sem condenação do Estado do Rio Grande do Sul em honorários advocatícios, por aplicável ao caso a Súmula 421 do STJ.

No que tange às custas processuais, e considerando a recente alteração do artigo 462 da Consolidação Normativa Judicial (PROVIMENTO N.º 028/2020- CGJ) incide, ante a data da propositura da demanda (após 15/06/2015), a atual redação. Assim, a taxa única será devida por inteiro pela Fazenda Pública, pois vencida no presente feito, devendo eventuais despesas serem por ela pagas integralmente.

Como o proveito econômico obtido é inferior a 500 salários-mínimos, aplica-se o art. 496, § 3º, II, do CPC, de modo que fica dispensada a remessa necessária.

Publicação, registro e intimação, eletronicamente.

Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido, baixe-se.

Documento assinado eletronicamente por **ANDRE LUIS DE MORAES PINTO, Juiz de Direito**, em 26/4/2022, às 16:20:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10018166398v18** e o código CRC **c947d9bc**.

---

1. AZEVEDO. Plauto Faraco. Direito, Justiça Social e Neoconstitucionalismo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 71. ↩
2. BONAVIDES Paulo. Curso de Direito Constitucional, 21ª edição atualizada. São Paulo: Malheiros Editores, 2007 p. 592. ↩
3. HÄBERLE, Peter. Libertad, Igualdad, Fraternidad. 1789 Como História, Actualidad y Futuro del Estado Constitucional. Tradução: Ignacio Gutierrez. Madrid: Editorial trotta, 1998. p. 47 ↩
4. BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. São Paulo: Editora Campus, 1992. p.24 ↩
5. MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional - Tomo II - Constituição e Constituição e Constitucionalismo. 3. ed. Coimbra: Editora Coimbra, 1996. p.177 ↩
6. DALLARI, Sueli Gandolfi. Os Estados Brasileiros e o Direito a Saúde. São Paulo: Huditec, 1995.p.32 ↩
7. VIGILAR, José Marcelo Menezes. Saúde Pública e Probidade Administrativa. In: Direito Sanitário e Saúde Pública. Volume I. Distrito Federal: Brasília, 2003. p.130. ↩
8. SANTOS, Lenir. O poder regulamentador do Estado sobre as ações e serviços de saúde. In: Saúde e Democracia, A luta do CEBES. Organizadora: Sônia Fleury. São Paulo: Editora Lemos, 1997. p. 254. ↩
9. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Malheiros, 2002.p.519. ↩
10. ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução Virgílio Afonso da silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 515-517. ↩
11. BARROSO. Luis Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.107-108. ↩
12. Quando se fala em norma programática se refere àqueles conteúdos constitucionais que são disposições indicativas de tarefas a serem realizadas, ou seja, fins a serem atingidos pelos Poderes Públicos face às prerrogativas constitucionais. Segundo alguns doutrinadores, seriam normas com certa vagueza de conteúdo, com baixa efetividade jurídica e social. O respeitável doutrinador português J.J. Canotilho em uma das suas mais conhecidas obras, declarou "a morte das normas programáticas", no sentido que não seria motivo para o não cumprimento de seus dispositivos. CANOTILHO, op. cit. ↩
13. SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais na Constituição de 1988. 5a Porto Alegre: Livraria do advogado, 2005. p. 296. ↩
14. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 5ª ed. Coimbra: Livraria Almedina, 2002. ↩
15. KRELL. Andréas J. Direitos Sociais e Controle Judicial no Brasil e na Alemanha. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 2002, 52-55, passim. ↩
16. Em sua obra, o autor demonstra a dificuldade de prover recursos financeiros para prover a gama de direitos constitucionalizados, por isso a referência que faz no título "direitos não dão em árvore", bem como não efetividade de muitos destes, é por opção política dos governantes. In: Introdução a teoria dos custos do Direito. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2005, p.212. ↩
17. SILVA. Anabelle Macedo. Concretizando a Constituição. Rio de Janeiro: Lumen Júris: 2005. p.163. ↩
18. Ibidem, p. 189. ↩
19. WEICHERT, Alberto Marlon. Saúde e Federação na Constituição Brasileira. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2004, p.120 ↩

20. FREITAS, Fernando Calil. Limites e restrições a direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2007. p. 197-198. ↩
21. ALEXY, Robert. Teoria de Los Derechos Fundamentales. Madrid: Centro de Estúdios Políticos y Constitucionales, 1997. p. 111-114. ↩
22. REIS, Jorge Renato; LEAL, Rogério Gesta (org). Direitos Sociais e Políticas Públicas: desafios contemporâneos. Tomo 6. Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2006, pp. 1531 e 1533. ↩
23. SARLET, Ingo Wolfgang. Direitos fundamentais sociais, "mínimo existencial" e direito privado: breves notas sobre alguns aspectos da possível eficácia dos direitos sociais nas relações entre particulares. In: Direitos Fundamentais. Estudos em homenagem ao professor Ricardo Lobo Torres. SARMENTO, Daniel. GALDINO, Flávio. Org. p. 587 ↩